

1500344-52.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não demonstrado prejuízo, a inversão da ordem das perguntas prevista no art. 212 do CPP não enseja nulidade. (...)" (TJMG - ApCrim 1.0024.09.547696-6/001, Rel. Des. Eduardo Machado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500344-52.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080820/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23818693 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2080820 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AIRTON DAVID CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

AIRTON DAVID DA CUNHA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2022, na rua José Domingues, nº 165, Centro, nesta cidade e Comarca, tentou subtrair, para si, bens pertencentes ao estabelecimento Emagrecentro, de

propriedade de Wagner Filipchiuk Filho, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia aos 31 de março de 2022 (fl. 64), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 70 e 74/75).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 77), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e uma da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 161).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 164/169).

A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade do depoimento dos policiais, a par da inobservância do artigo 212, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária com a desclassificação do crime de furto tentado para o delito de invasão de domicílio. No mais, rogou pela aplicação da detração penal e pela possibilidade de que o acusado aguarde eventual recurso em liberdade (fls. 173/181).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não prospera a alegação defensiva de nulidade na colheita da prova oral por violação ao artigo 212 do CPP, sob o argumento de que o Juízo teria incorrido em "error in procedendo" ao iniciar, ele próprio, a inquirição das testemunhas.

Não lhe assiste razão alguma. Isso porque restou inafastável a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição e da legislação processual penal, permitindo-se ao combativo defensor presente ao ato formular suas perguntas e exercer adequadamente seu múnus, não se extraindo qualquer prejuízo à defesa do réu.

Afinal, a prova é produzida pelo Juízo e para o Juiz, portanto, nada impede que ele inicie as oitivas, desde que seja ofertada às partes oportunidades de inquirirem a testemunha. Ademais, é até preferível que o façam posteriormente ao juiz, pois, além de avaliarem as respostas iniciais da testemunha, podem ter oportunidade de esclarecer eventuais incertezas ou dúvidas.

Não bastasse, a teor do artigo 563, do mesmo Estatuto Processual, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", sendo certo que, na hipótese vertente, não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa.

Veja-se, a respeito:

Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo e munição, de uso permitido -

Recurso da defesa - Preliminar de nulidade - Violação ao disposto no artigo 212,

CPP - Inocorrência - Prejuízo não demonstrado - Nulidade relativa - Mérito -

Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas pelas provas, oral e técnica - Negativa de autoria que foi infirmada pelas palavras dos guardas civis municipais, seguras e sem contradições -

Condenação mantida - Penas estabelecidas no piso - Carcerária substituída por penas restritivas de direitos - Regime prisional aberto para a hipótese de descumprimento e conversão - Preliminar rejeitada - Apelo não provido. (TJ-SP - APL:

00014277820148260604 SP 0001427-78.2014.8.26.0604, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 27/10/2016, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DETERMINADA NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA

- NULIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não

demonstrado prejuízo, a inversão da ordem das perguntas prevista no art. 212 do CPP não enseja nulidade. (...)" (TJMG - ApCrim 1.0024.09.547696-6/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/08/2010, publicação da súmula em 01/09/2010).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU. OITIVA DE TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DO IMPULSO OFICIAL. NULIDADES RELATIVAS. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATESTADO MÉDICO. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)" 3. As modificações introduzidas pela Lei n. 11.690/08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório. 4. Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, não logrando demonstrar qual o prejuízo causado ao réu. (...)" (STJ - HC 295.979/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

Na mesma esteira, a divergência quanto aos policiais que realizaram a captura do acusado e aqueles que prestaram depoimento, arguida pelo interrogado e ratificada pela defesa, confunde-se com o mérito, razão pela qual com ele será analisada. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 06/08), pelas imagens de fls. 31/35 e pelo auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração.

Airton argumentou que não é a pessoa que aparece nas imagens captadas pela câmera de segurança instalada no local (fls. 33/35), bem como que, depois de ter sido preso naquela ocasião, teria sido obrigado pelos policiais a trocar de roupa, colocando a blusa e a bermuda utilizadas pelo indivíduo que havia perpetrado a ação criminosa, tudo para que se parecesse com a pessoa flagrada nas imagens. Defendeu-se dizendo que sua captura não foi realizada pelos mesmos policiais que prestaram depoimento durante a instrução processual.

Eis suas palavras:

J.: O senhor não entrou no estabelecimento lá então, né?

D.: (fica em silêncio)

J.: Entrou ou não entrou? Não?

D.: (Fica em silêncio)

J.: Dona Gabriele, por favor, folhas 34. O senhor está vendo essa imagem aí?

D.: Estou sim vossa excelência.

J.: É do rapaz que adentrou lá no dia, tá certo? É o senhor aí?

D.: Não senhor.

J.: Não. Muito bem. Folhas 32, por favor, dona Gabriele. Esse é o senhor?

D.: Sim senhor.

J.: O senhor não acha estranho que o senhor estava usando a mesma roupa, uma roupa idêntica a do rapaz que entrou na loja lá?

D.: (fica em silêncio)

J.: O que o senhor tem a dizer sobre isso?

D.: Tenho a dizer que a roupa não é compatível, porque eu não estava exatamente com a roupa dessa forma, eu estava com uma blusa por cima.

J.: Esse capuz aqui malhado que forma de exército, igualzinho lá o da loja não é, o

senhor não tem nada a dizer sobre isso?

D.: Não, é o que eu estou mencionando ao senhor, é, a minha roupa não estava dessa forma. Eu fui obrigado a mudar a minha roupa...

J.: O senhor não estava com essa roupa então? Obrigaram o senhor a pôr essa roupa, é isso?

D.: Não que me obrigaram. Eu tava com a roupa normal, eu tava com essa blusa camuflada mesmo, eu tinha comprado até uns dias antes, porém, dentro da delegacia eles me obrigaram a colocar, tipo, colocar a roupa da forma que eles queriam e tiraram a foto com essa roupa.

J.: Obrigaram a pôr essa roupa.

D.: Exato.

J.: O senhor conhecia os policiais que capturaram o senhor? Tem alguma coisa contra eles?

D.: É, ressaltando vossa excelência, que os policiais que me abordaram de verdade não foram os policiais que deram depoimento agora nesse momento. Foi uma policial feminina, eu não me recordo o nome dela, mas eu me lembro da fisionomia, até mesmo porque ela utilizava óculos, e ela me mostrou uma das imagens que no caso a vítima, no dia, havia mostrado pra ela, porque a vítima estava presente no momento da abordagem, e ela me mostrou através do celular da vítima.

Sua escusa não convenceu e restou isolada.

Primeiramente, observa-se que durante a etapa policial ele se calou.

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo”.

Somente em Juízo alegou que não seria ele a pessoa flagrada pela câmera de segurança. Ora, sequer comprovou o teor de suas palavras, ônus que lhe incumbia diante das evidências expostas, tudo não passando do plano da argumentação. Lado outro, seu argumento de que os policiais teriam lhe obrigado a vestir as roupas utilizadas pelo suposto agente para que se parecesse com ele é totalmente descabido e afronta o raciocínio lógico deste Juízo.

Ele também não apresentou justificativa por quais motivos poderiam a vítima e testemunhas querer incriminá-lo injustificadamente.

Desta forma, desacreditadas suas palavras, em especial diante do acervo que se reproduzirá adiante.

Em brilhante decisão, da lavra do Des. José Raul Gavião de Almeida, que tomamos da liberdade de reproduzir, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a versão do acusado, quando esposada, deve ser comprovada para merecer confiabilidade.

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta.

Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se.

Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade.

Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito à valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa.

Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da autodefesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional.

Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras,

porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor.

É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade”.

Se não bastasse a força de convicção íntima em tais elementos, o depoimento harmônico e coerente das testemunhas ouvidas durante a instrução processual corrobora com a certeza da autoria e a materialidade. Senão vejamos.

Wagner, representante da empresa-vítima, narrou que na ocasião dos fatos recebeu chamado da empresa de segurança “Verisure”, responsável pelo monitoramento da sua empresa, informando que um indivíduo teria invadido o local e disparado o alarme. Diante disso acionou a polícia militar e se dirigiu ao seu estabelecimento comercial.

Declarou que, com o auxílio da polícia militar, adentrou ao estabelecimento e observou que nenhum bem havia sido subtraído, pois o local apenas estava revirado. Em seguida, exibiu aos policiais as imagens do momento da prática criminosa, captadas pela câmera de segurança existente no local, oportunidade em que foi possível constatar que uma pessoa do sexo masculino havia entrado ao imóvel.

Acrescentou que depois de ter visualizado as imagens, os policiais realizaram diligência pelas proximidades e se depararam com o acusado, que possuía as mesmas características, inclusive iguais vestimentas, do indivíduo flagrado pela câmera de segurança, quando então o capturaram.

Disse, ainda, que posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como sendo a pessoa que aparecia nas filmagens. Asseverou que, embora não fosse possível visualizar o rosto do acusado, pela sua estrutura física e vestimentas utilizadas pôde reconhecê-lo claramente.

Por sua vez, o PM Euclides narrou que foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de furto ocorrida no interior da empresa Emagrecentro, motivo pelo qual para lá se dirigiu. Declarou que fez contato com o proprietário do estabelecimento, oportunidade em que ele lhe exibiu as imagens obtidas no momento da ação criminosa. Assim, de posse das características físicas do agente, realizou diligências pelas proximidades do local e se deparou com o acusado, que possuía os mesmos atributos, além de vestir roupas idênticas daquela pessoa que aparecia nas filmagens, motivo pelo qual o abordou. Indagado a respeito dos fatos, o acusado admitiu informalmente a prática da infração e lhe confidenciou que de fato tinha adentrado ao local para subtrair bens, porém, quando o alarme disparou, ele fugiu sem levar nenhum objeto.

Por fim, o PM Josinei, testemunha de defesa ouvida, corroborou com as demais provas. Ele declarou que naquela ocasião, após ser acionado pela empresa de segurança e monitoramento da Emagrecentro, compareceu ao local. Depois de visualizar as imagens e características do agente, patrulhou pelas proximidades e capturou o acusado, que possuía as mesmas características do indivíduo flagrado pelo monitoramento. Salientou que quando exibiu ao acusado as imagens captadas no momento da ação criminosa, ele acabou por admitir a prática da infração.

A par disto, confrontando-se as imagens da câmera de segurança no momento da ação criminosa (fls. 33/35) com as fotos do acusado obtidas pelos policiais após a prática criminosa (fls. 31/32), constata-se a semelhança entre eles, fator que corrobora com a certeza da autoria.

Pontue-se, ainda, que a vítima indicou seguramente que Airton era a pessoa captada pelas câmeras de segurança instaladas no local, flagrado no momento em que dali saía, logo após o acionamento do alarme.

Ora, a palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade.

Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO AUTORIA DELITIVA PROVADA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL VALIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA. Acusado que foi reconhecido com segurança, por fotografia, na delegacia, e, em Juízo, pessoalmente, pela testemunha presencial. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de acusado que subtraiu coisa alheia móvel, mediante arrombamento, por duas vezes em continuidade delitiva,

de rigor a manutenção do decreto condenatório. (TJ-SP - APL: 00722569220108260000 SP 0072256-92.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 05/03/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2013)

FURTO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Negativa do réu - Reconhecimento fotográfico feito na delegacia e pessoal perante o juízo - Validade - Materialidade e autoria comprovados - Princípio da insignificância afastado - Crime de bagatela - Atipicidade material da conduta que não pode ser reconhecida - Condenação mantida - Pena imposta que decorre de criteriosa análise e individualização - Montante da reprimenda que autoriza o regime semiaberto independente da reincidência reconhecida - Recurso parcialmente provido - (voto nº 24854). (TJ-SP - APL: 00175014120118260079 SP 0017501-41.2011.8.26.0079, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 12/05/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/05/2015).

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração.

As combativas alegações da defesa carecem de razão. A prova amealhada é plena e está em harmonia com os demais elementos existentes.

Não há que se falar em desistência voluntária com consequente desclassificação do furto para o crime de invasão de domicílio, pleiteada pela defesa. Pelos testemunhos colhidos ficou evidente que o acusado fugiu do local quando o alarme disparou. Portanto, não houve desistência da conduta criminosa, mas sim a não consumação do furto por circunstâncias alheias a sua vontade.

Eis a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA BEM COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. Reconhecimento de desistência voluntária - Impossibilidade - Uma vez que o acusado deixou de dar prosseguimento na execução do crime, não por ato voluntário, mas sim por circunstâncias alheias à sua vontade (chegada da vítima), não há se cogitar em caracterizada a desistência voluntária, instituto previsto no art. 15, do CP. Arrependimento eficaz que não se cogita. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00062518520118260022 SP 0006251-85.2011.8.26.0022, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/05/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/05/2016).

APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE PROVADAS. CONDENAÇÃO.

POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA E APLICAÇÃO DE "SURSI" PROCESSUAL.

IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL PARA EVITAR "REFORMATIO IN PEJUS".

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. POSSIBILIDADE. DECRETO DE EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE.

APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. No caso dos

autos, a conjugação dos elementos probatórios (prisão em flagrante, confissão do

réu em Juízo, e depoimentos de policiais e testemunha civil) leva ao suficiente

grau de certeza quanto à autoria e à materialidade do fato descrito na denúncia.

Não cabe reconhecer a desistência voluntária quando o agente interrompe a prática

delitiva em virtude da aproximação de policiais, pois a concreta iminência da

prisão em flagrante é fato alheio à sua vontade. O instituto da detração, para ser

aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no

que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das

Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. (TJ-SP - APL:

00831252720118260050 SP 0083125-27.2011.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de

Julgamento: 15/09/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação:

18/09/2014).

Por fim, caracteriza-se o furto tentado quando comprovado que o acusado não conseguiu tirar o objeto furtado da esfera de vigilância da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sobre o tema:

Furto tentado - Objeto que não saiu da esfera de vigilância da vítima - Ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva - Irrelevância para a tipificação do crime na forma tentada - Condenação mantida; Furto tentado - Dependência química - Ausência de laudo - Irrelevância para a tipificação do crime se o agente admite que tinha plena ciência da ilicitude do fato e declara que estava sóbrio quando o praticou - Crime configurado; Furto tentado - Confissão parcial - Circunstância de que deve ser considerada na dosimetria da pena - Inteligência da Súmula nº 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido.(TJ-SP

00021109420168260168 SP 0002110-94.2016.8.26.0168, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 11/10/2017, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2017).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 43/44), suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar (1 ano + 1/6 = 1 ano e 02 meses/10 dias + 1/6 = 11 dias-multa).

Por último, causas gerais ou especiais de aumento não foram cogitadas.

Em virtude da tentativa as penas serão diminuídas em 1/2, visto que o agente estava próximo da consumação, já havia adentrado ao local e revirado os bens, somente fugindo com o acionamento do alarme (1 ano e 02 meses - ½ = 7 meses/ 11 dias -1/2 = 5 dias-multa).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR AIRTON DAVID CUNHA qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor supra especificado, face sua situação econômica.

A reincidência impede a suspensão condicional da pena, bem como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

Considerando o tempo de prisão cautelar decorrido e a pena aplicada, faculto o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 08 de agosto de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA